

المبحث الثالث: أنواع القاعدة القانونية

حسب المعيار الراجح في الفقه تنقسم فروع القانون تقسيماً يقوم على أساس وجود الدولة وصفتها أو عدم وجودها في العلاقات القانونية التي تحكمها تلك القواعد فإذا كانت الدولة طرفاً في العلاقة الذي ينظمها القانون بصفتها صاحبة السيادة والسلطة فإن هذه العلاقة تدخل تحت قواعد القانون العام، كما لو قامت الدولة بانتزاع ملكية قطعة أرض لاستخدامها للمنفعة العامة، كبناء مدرسة أو مستشفى أو شق طريق فيها

أما لو كانت الدولة طرفاً في العلاقة القانونية لا بصفتها صاحبة السلطة والسيادة بل باعتبارها شخصاً عادياً كباقي الأشخاص، كأن تقوم الدولة مثلاً بتأجير قطعة أرض تملكها أو تستأجر مبنى لاستخدامه كمدرسة أو مستشفى. أو كانت العلاقة فيما بين الأفراد وبعضهم البعض فإنها تدخل تحت قواعد القانون الخاص.

ومن هنا يتبين لنا أن قواعد القانون العام هي تلك القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بوصفها صاحبة السلطة والسيادة.

أما القانون الخاص فهو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين الأشخاص وبعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة باعتبارها شخصاً عادياً وليس باعتبارها صاحب السلطة والسيادة ومنه فقد قسم الفقهاء قواعد القانون إلى قواعد عامة وخاصة أو ما يعرف بالقانون العام والقانون الخاص وكل من هذين القسمين عدة فروع وهو ما سنحاول التطرق إليه عبر المطالب التالية:

المطلب الأول: القانون العام

كما أشرنا آنفاً تعرف قواعد القانون العام أنها القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بوصفها صاحبة السلطة والسيادة، ويذهب الفقه إلى تقسيم القانون العام إلى عدة فروع نذكر منها على سبيل المثال:

القانون الدولي العام: هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدولة بعضها ببعض الآخر في وقت السلم والحرب والحياد وعلاقاتها بالمنظمات الدولية.

القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في وقت السلم يسمى بقانون السلم، ويحدد هذا القانون أشخاص المجتمع الدولي مبيناً شروط ومقومات قيام الدول، كما ينظم حقوق الدول وواجباتها في علاقتها بالدول الأخرى، كما ينظم القواعد المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية كالقواعد التي تنظم تبادل السفراء والحصانات والامتيازات التي يتمتع بها أعضاء السلك الدبلوماسية... الخ، كما ينظم الوسائل الواجب اتباعها لفض المنازعات بالطرق السلمية كالمفاوضة والتحقيق والوساطة والتحكيم.

كما يتناول القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول في حالة الحرب، وهذه ينظمها ما يسمى بقانون الحرب، فيحدد القواعد الواجب اتباعها في معاملة الأسرى

توقيف الحرب، كما يبين الاسلحة المحرمة في الحرب ومركز الدول المتحاربة والدول المحايدة.

القانون الدستوري:

القانون الدستوري: هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة ونظام الحكم وسلطات الدولة واختصاصاتها وعلاقاتها ببعض، وتقرر ما للأفراد من حقوق وما عليهم من واجبات، والقانون الدستوري هو أساس تنظيم الدولة، ونتيجة لسموه فإنه لا يجوز أن يصدر قانون آخر داخل الدولة يتعارض مع الدستور لأن القوانين الأخرى أقل مرتبة منه.

ويتضمن القانون الدستوري موضوعات عديدة فهو يبين شكل الدولة، ونظام الحكم فيها ملكي أم جمهوري أم ديمقراطي أم رئاسي أم برلماني، كما يبين السلطات العامة في الدولة واختصاصاتها وهذه السلطات هي السلطة التشريعية التي تسن القوانين، والسلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القوانين وإدارة المرافق والمؤسسات العامة، والسلطة القضائية والتي تقوم بالفصل في المنازعات بين الأشخاص وفقاً للقانون، كما يبين الدستور حقوق الأفراد والتي تتركز في الحرية والمساواة

القانون المالي:

يقصد به مجموعة القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث بيان موارد الدولة وأوجه انفاقها، ومن أهم موارد الدولة والتي يحددها القانون المالي تلك التي تأتي من موارد الدولة الخاص وعن طريق الضرائب والرسوم والقروض وهذه الموارد يقوم القانون المالي أيضاً بتحديد الأوجه التي تنفق فيها وهي الخدمات والمرافق المختلفة في الدولة كالتهليم والدفاع والأمن والصحة... الخ

القانون الإداري:

يعني مجموعة القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الإدارية، فهو يبين الخدمات العامة التي تؤديها السلطة التنفيذية للأفراد والمرافق العامة التي تقوم بتلك الخدمة

كما يبين كيفية إدارة المرافق واستغلالها وعلاقة المرافق بعضها ببعض والأشخاص العامة التي تتولى إدارة هذه المرافق كرئيس الدولة والوزراء ومدراء المصالح الحكومية. أيضاً ينظم القواعد المتعلقة بالوظيفة العامة وعلاقة الدولة بالموظفين وتولي الوظائف العامة وحقوق الموظفين وواجباتهم وذلك من حيث التعيين وتحديد المرتبات والترقية والاستقالة والإحالة إلى التقاعد.

المطلب الثاني: القانون الخاص

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين الأشخاص وبعضهم البعض أو بينهم وبين الدولة، وينقسم القانون الخاص إلى عدة فروع حسب المجال الذي ينظمه كل فرع وسنقتصر على أهم تلك الفروع

القانون المدني:

هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص عدا ما يدخل في فرع آخر من فروع القانون الخاص. والقانون المدني هو أصل القانون الخاص وقواعده تتوجه إلى جميع الأفراد دون استثناء ويتم الرجوع إليها في كل حاله لم يتناول تنظيمها فرع آخر من فروع القانون الخاص

القانون التجاري:

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات التي تتعلق بالأعمال التجارية، ويتضمن القانون التجاري تعريف التاجر وكيفية اكتساب صفة التاجر والأعمال التجارية التي يسري عليها القانون التجاري كما يبين واجبات التاجر، كالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية ويبين أيضاً الشركات التجارية وأنواعها

القانون البحري:

مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية، وقواعد القانون البحري تركز حول السفينة، لذلك فإنه يتضمن قواعد بيع السفينة وشراؤها والعقود التي ترد عليها كتأجيرها ورهنها وإيجارها، والتأمين عليها، وصلة ريان الملاحة وملاحيتها بمالك السفينة، والإنقاذ والمساعدة البحرية التي تقدمها سفينة لأخرى في حالة جنوحها أو غرقها ... إلى غير ذلك من القواعد المنظمة للملاحة البحرية، وإذا كانت المسائل التي يقوم بتنظيمها القانون البحري تعتبر من قبل الأعمال التجارية إلا أن هناك اعتبارات دعت إلى استقلاله عن القانون التجاري، هذه الاعتبارات ترجع إلى كبر قيمة السفينة وأنها تتعرض لأخطار خاصة وهي في غالب الأحيان بعيدة عن رقابة مالكيها.

القانون الجوي:

ينظم القانون الجوي العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية، فيتضمن تحديد المراكز القانونية للطائرة من حيث ملكيتها وجنسياتها وتسجيلها، كما يحدد المراكز القانونية لطاقم الطائرة ومسؤولية الناقل الجوي... إلى غير ذلك من القواعد المنظمة للملاحة الجوية.

قانون العمل:

هو مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال. وقانون العمل حديث النشأة، حيث كانت العلاقة الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال محكومة بقواعد القانون المدني، ونتيجة لما حدث من تطورات اقتصادية في العالم أدى إلى وجود قواعد قانون العمل. ويتضمن قانون العمل تنظيم عقد العمل والأحكام الخاصة بانتهاء العقد وحقوق العمال وواجباتهم



المبحث الرابع: مصادر القانون

بعد أن تطرقنا إلى مفهوم القاعدة القانونية وخصائصها يجدر بنا أن نتطرق إلى كيفية ظهورها إلى حيز الوجود واكتسابها صفة الإلزام وذلك بدراسة مصادرها ومراحل تشريعها.

فوجود القاعدة القانونية هو نتاج تجمع وتفاعل عدة عوام هي التي تكون جوهر القاعدة القانونية ثم نصيغها الصياغة الفنية في قالب قابل للتطبيق العملي، فالعوامل التي تتكون منها مادة القانون لا بد من أن يتوفر لها جانبان جانب الجوهر وجانب الصياغة، ثم بعد ذلك يتوفر لها عنصر الإلزام الذي يخرجها من مجرد قاعدة سلوكية عادية إلى قاعدة قانونية ملزمة.

وعلى هذا يمكن تعريف مصدر القانون بأنه الأصل أو المنبع الذي يستقى منه المشرع جوهر القانون وصفة إلزامه، فكل أصل من الأصول الواقعية أسهم في خلق وتكوين القاعدة القانونية نقول عنه إنه مصدر للقانون. فكل قاعدة قانونية لا بد لها من مصدر مادي تستمد منه مادتها (جسمها) ومصدر رسمي تستمد منه قوتها (روحها).

فبالعودة إلى أية قاعدة قانونية وقراءتها قراءة تحليلية نجدها تتكون من عنصرين: العنصر الأول: يتعلق بتنظيم لشأن معين من شؤون الجماعة ويطلق على هذا العنصر (جسم القاعدة القانونية أو مادتها).

والعنصر الثاني: هو الإلزام أو الإجبار الذي تضيفه الدولة على القاعدة القانونية لتكفل احترامها ويطلق على هذا العنصر روح القاعدة القانونية أو رسميتها. فالقاعدة القانونية التي تحرم السرقة تتضمن المنع من السرقة وتتضمن الجزاء المادي الحال الذي من شأنه أن يجعلها ملزمة للأشخاص.

ولعل هذا م جعل بعض الفقه في العصر الحديث يقسم مصادر القانون إلى نوعين فقط مصادر مادية ومصادر رسمية.

ويقصد بالمصدر المادي هنا والذي يطلق عليه أيضا المصدر الموضوعي مجموع العوامل المختلفة التي تستمد منها القاعدة القانونية مضمون التنظيم الذي تنطوي عليه أو بمعنى آخر فهي تعني مجموع الأصول التي تساهم في تكوين القاعدة القانونية والتي تستمد من الواقع تارة ومن الفكر أو الوسط الطبيعي أو الاجتماعي تارة أخرى. فاستخراج المادة الأولية للقاعدة القانونية يأتي من اجتماع هذه الأصول وتفاعلها والموازاة بينها، وذلك لأن القانون وليد البيئة الاجتماعية.

وبعد هذا التقديم فإننا نرى بأن دراسة مصادر القانون تتطلب منا أن نقسم هذا المبحث إلى أربعة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول: المصدر الموضوعي أو الحقيقي

المطلب الثاني: المصدر التاريخي

المطلب الثالث: المصدر الرسمي أو الشكلي

المطلب الرابع: المصدر التفسيري

وسنتعرض لكل واحد من هذه المصادر في مطلب مستقل وقبل ذلك نشير إلى أن من الفقهاء في العصر الحديث من يقف عند المصادر الرسمية أو التفسيرية ويرى أن ما ينسب عادة إلى المصادر الموضوعية للقانون بما في ذلك العوامل التاريخية والقانون الطبيعي والعدالة والمبادئ العامة للقانون يتعلق في الواقع بأساس القانون وليس بمصدره وهذا هو الاتجاه السائد في الفقه الفرنسي ومنهم من يرى بأنه لا فرق بين المصدر الموضوعي والمصدر التاريخي.

المطلب الأول: المصادر الموضوعية

ويقصد بها الأصل الذي استمد منه القانون موضوعه وقواعده وتحديد المصدر الموضوعي عادة ما يرجع إلى البحث الذي غالبا ما يكون الفقيه وإن كان القاضي والمحامي ورجل الإدارة قد يهمهم مصدر القاعدة وذلك ليستطيعوا تفسيرها والسؤال الذي يهمنا هنا هو ما هي المصادر الموضوعية للقانون الموريتاني؟ يمكن تلخيص المصادر الموضوعية للقانون الموريتاني فيما يلي:

أولا: الشريعة الإسلامية:

لقد ظلت الدساتير الموريتانية المتلاحقة كدستور 22 مارس 1959 و20 مايو 1961 تؤكد على أن دين الشعب الموريتاني هو الإسلام أما الميثاق الصادر في 9 فبراير 1985 فقد نص في مقدمته على أن المصدر الوحيد للقانون الموريتاني هو الشريعة الإسلامية، كما دستور 1991 في ديباجته على احترام مبادئ الدين الإسلامي المصدر الوحيد للقانون، وإذا نظرنا إلى القوانين نجد أن هناك فعلا قوانين استمدت مضمونها من الشريعة الإسلامية ونذكر منها مثلا القانون الجنائي الصادر 1972 والمعدل بالقانون رقم 83/286 بتاريخ 12 مايو 1983 والذي تضمن جزاءات مأخوذة من الكتاب والسنة كالمواد المتعلقة بالقصاص من 280 - 285 والمواد المتعلقة بالدية وهي من 285 - 286 وجلد الزاني المواد 307 - 308 أو رجمه أو قطع يد السارق المادة 351 ... وكقانون الالتزامات والعقود الموريتاني الصادر 1989 والذي تضمن قواعد ترجع إلى ما هو سائد في الفقه الإسلامي ومنها تنظيم عقد الهبة والتقادم الذي يسقط الدعوى ولا يسقط الحق المادة 269 من ق. ا. ع. م.

وقد نصت المادة 1179 على أنه «يرجع إلى مذهب الإمام مالك في كل ما لم ينص عليه في هذا الأمر القانوني».

وفي هذه المادة دلالة على أن هذا القانون قد استند بوجه عام على الشريعة الإسلامية.

كما نجد أيضا أن المشرع الموريتاني قد استمد نصوص مدونة الأحوال الشخصية التي صدرت أخيرا من الشرع الإسلامي.

ثانيا: قوانين بلدان المغرب العربي

لقد تأثر القانون الموريتاني بحكم التاريخ والجغرافيا بقوانين بلدان المغرب العربي وهكذا جاء قانون الالتزامات والعقود الصادر بتاريخ 1989/09/14 مستمدا معظم أحكامه من قانون الالتزامات والعقود المغربي الصادر 1913 والمستمذ هو الآخر من قانون ا ع التونسي الصادر 1906 اللذين أخذوا بالمذهب المالكي في المعاملات مع الاستفادة كثيرا من القانون المدني الفرنسي الذي أخذ عنه بعض الأحكام مع تطويرها إلى ما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما فعلا مثل بالنسبة إلى مؤسسة التعهد عن الغير الذي طوراه إلى ما يسمى بالالتزام عن الغير على شرط إقراره إياه.

كما تأثر أيضا قانون الالتزامات والعقود الموريتاني في الكتاب الأول القسم الأول المخصص لأحكام عامة المواد من 1 - 21 بالقانون المدني الجزائري فأخذ عنه أحكاما تتعلق بنفاذ القانون وتنازع القوانين والشخصية القانونية والأهلية.

ثالثا: التشريع الفرنسي الوطني لطلبة

يلاحظ أن الدساتير الموريتانية بما فيها دستور 1991 كانت تعتمد في كثير من الحالات على الدستور الفرنسي، وعلى العموم فإن القانون الفرنسي يعتبر مصدرا موضوعيا لكثير من التشريعات الموريتانية خاصة فيما يتعلق بتنظيم الدولة وتنظيم الإدارة.

المطلب الثاني: المصدر التاريخي

ويقصد به الأصل الذي يرجع إليه قانون معين والذي يتمثل في أنظمة وأوضاع سابقة فاحتكاك الحضارات وتأثر المجتمع بحكم تاريخه وتطوره الداخلي قد يكون هو منطلق الفكرة القانونية.

فالقانون الروماني مثلا يعتبر مصدرا تاريخيا لكثير من القوانين في أوروبا وانطلاقا من هذا المفهوم فإنه يكون مصادر تاريخية للقانون الموريتاني كل من الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسية وكذلك القانون الروماني.

أ - الشريعة الإسلامية

لقد سبقت الإشارة إلى أن الشريعة الإسلامية تعتبر مصدرا موضوعيا للقانون الموريتاني في مجالات مختلفة غير أن القانون الموريتاني قد استمد قواعده من قوانين بلدان المغرب العربي كما سبق وأن ذكرنا وقوانين بلدان المغرب العربي هذه قد استمدت تلك القواعد من الشريعة الإسلامية وبذلك تكون الشريعة الإسلامية مصدرا موضوعيا لقوانين بلدان المغرب العربي ولكنها في هذه الحالة مصدرا تاريخيا بالنسبة للقانون الموريتاني.

فإذا كان بيع السلم 1 مثلا قد نظمته ق. ا. ع. م. من المواد 602 - 605 فإن هذه المواد جاءت مطابقة للفصول من 613 - 618 من ق. ا. ع. المغربي والتي جاءت هي الأخرى شبه مطابقة للمواد من 712 - 717 من ق. ا. ع. التونسي والتي تم نسخها فيما بعد من القانون رقم 1 لسنة 1958 فيمكننا أن نعتبر في هذه الحالة أن القانون المغربي مصدرا موضوعيا للقانون الموريتاني.

أما القانون التونسي فهو مصدر تاريخي للقانون الموريتاني ولكننا نلاحظ أيضا أن تنظيم بيع السلم الذي جاء به المشرع التونسي لا يتعدى تدوين ما هو سائد في الفقه الإسلامي وحين إذن سندرك أن الشريعة الإسلامية هي المصدر التاريخي لقواعد هذا البيع التي وردت في القانون الموريتاني.

ب) - القانون الفرنسي:

بالإضافة إلى كون القانون الفرنسي يعتبر مصدرا موضوعيا للقانون الموريتاني فإنه يعتبر أيضا مصدرا تاريخيا له في كثير من الحالات وخاصة الحالات التي كانت فيها قوانين بلدان المغرب العربي مصادر موضوعية للقانون الموريتاني.

ت) - القانون الروماني

ويعتبر هذا القانون مصدرا تاريخيا للقانون الموريتاني على الرغم من أن موريتانيا لم تتصل بالحكم الروماني عبر التاريخ وأن القانون الروماني يرجع إلى عهد بعيد والسبب في ذلك يعود إلى القانون الفرنسي الذي أقر مبادئ وقواعد عديدة وضعها رجال القانون في عهد الرومان كما هو الحال مثلا في القاعدة التي تقول "لا عذر لأحد في جهل القانون" والقاعدة الأخرى "المقد شريعة المتعاقدين"، وبما أن القانون الموريتاني أخذ هذه القواعد عن القانون الفرنسي فقد أصبح القانون الروماني مصدرا تاريخيا له.

ث) - قوانين مختلفة

لقد ذكرنا بأن القانون المغربي والجزائري والفرنسي تعتبر مصادر موضوعية للقانون الموريتاني ولكن هذه القوانين قد استفادت هي الأخرى من قوانين بلدان عديدة مما يترتب عليه أن تكون قوانين تلك البلدان مصادر تاريخية للقانون الموريتاني فعلى سبيل المثال إذا نظرنا إلى المواد 40، 41، 42، 43 من ق. ا. ع. م المتعلقة بإنشاء العقد والتحفظات الواردة عليه نجدها مستمدة من ق. ا. ع. المغربي غير أنها مقابلة للمواد 154، 155، 145 من القانون المدني الألماني وعليه يكون القانون الألماني مصدرا تاريخيا لقانون إ. ع. م.

المطلب الثالث: المصادر الرسمية

وتنقسم المصادر الرسمية إلى مصادر رسمية مباشرة ومصادر رسمية غير مباشرة.

أ - المصادر الرسمية المباشرة

ويتمثل المصدر الرسمي المباشر أساسا فيما يسمى بالتشريع وقد أصبح التشريع في العصر الحاضر هو المصدر الرسمي الأصلي للقانون بل إن معظم البلدان ذات الأنظمة المتطورة تعتبر المصدر الأصلي الوحيد وما دونه يعتبر مصادر احتياطية أو تفسيرية كأعمال القضاء وقواعد العدالة.

وقد سعت موريتانيا منذ الاستقلال كغيرها من البلدان النامية إلى جعل التشريع المصدر الرسمي الأساسي لقوانينها ورغم ذلك فإن التشريع ليس هو المصدر الوحيد للقانون الموريتاني فهناك أيضا العرف والشرعة الإسلامية اللذان يشكلان هنا الآهران مصادر رسمية للقانون الموريتاني حيث تستمد منهما القواعد القانونية بشكل مباشر ولكن متى وجد التشريع فإنه يعلو على المصادر الأخرى والقاضي ملزم به.

وللتشريع مفاهيم مختلفة فهو مصدر من شرع أي سن القوانين فيقال إن سلطة التشريع ترجع إلى الهيئة المختصة أي للبرلمان أو ما يقوم مقامه، كما يطلق التشريع على مجموعة القوانين الوضعية المكتوبة والسائدة في البلد أو في مجال معين فيقال بهذا المفهوم: التشريع الصادر بعد دستور 1991 ويقال تشريع الشغل أي المعمول به في مجال الشغل كما يطلق أيضا التشريع على النصوص الصادرة في موضوع معين عن السلطة التشريعية المختصة فيقال صدر تشريع أو قانون جديد ينظم التجارة أو النقل البحري.. وهذا هو المفهوم الذي يعبر عنه بلفظ (قانون).

وتجدر الإشارة إلى أن معالجة التشريع كمصدر للقانون تشمل المفهومين الثاني والثالث أي تارة سائر القوانين الوضعية المكتوبة بغض النظر عن الجهة الصادرة عنها وتارة النصوص القانونية الصادرة عن الهيئة التشريعية.

والتشريع بمفهومه الواسع يظهر في الواقع بأشكال ودرجات مختلفة:

ما يصدر عن السلطة التشريعية أي البرلمان أو ما ينوب عنه وهذا هو التشريع أو القانون بمفهومه العادي والمفروض أن التشريع يصدر أصلا عن الهيئة التشريعية دون غيرها وإن كان يمكن في بعض الحالات صدوره عن الشعب مباشرة كما هو الحال في الاستفتاء أو عن السلطة التنفيذية التي تحل محل السلطة التشريعية وتمارس سلطاتها وذلك في حالات خاصة تختلف حسب ما إذا كانت السلطة التشريعية موجودة أو غير موجودة ويدخل في هذا المفهوم النصوص ذات الطابع التشريعي سواء سميت من الناحية الشكلية بقوانين إن صدرت عن البرلمان أو بأوامر قانونية إن صدرت عن هيئات تمارس مقام البرلمان.

يضاف إلى هذا كتشريع فرعي ما يصدر عن السلطة التنظيمية التي تمارس التنفيذية وتسمى هذه النصوص بالنصوص التنظيمية.

وقد تعرضنا إلى هذه المواضيع بالتفصيل عند دراسة أنواع القاعدة القانونية (التشريع أو التنظيم).

ب - المصادر الرسمية الاحتياطية

وتتمثل في الشريعة الإسلامية والقضاء والعرف

1 - الشريعة الإسلامية: قد يوجد تشريع ينظم وضعاً معيناً ولكنه يتضمن سكوتاً أو تحديداً غير كافٍ في بعض الحالات الأمر الذي يؤدي بالقاضي إلى البحث في مصادر احتياطية يستمد منها الحل المطلوب ويتحقق ذلك على أساس قواعد عامة واردة في الدستور أو في قوانين أساسية فـ قانون ا. ع. م. مثلاً الصادر سنة 1989 استمد عدداً وافراً من أحكامه من الشريعة الإسلامية سواء كان ذلك صفة مباشرة أو غير مباشرة ولذلك فقد نصت المادة 1179 على أنه «يرجع إلى مذهب الإمام مالك في كل ما لم ينص عليه في هذا الأمر القانوني...» ومعنى هذا أن القاضي في مجال الالتزامات والعقود يطبق أولاً الأمر القانوني فإذا لم يجد فيه القاعدة التي يحتاج إليها يرجع إلى الشريعة الإسلامية وخاصة المذهب المالكي كمصدر احتياطي بالنسبة لقانون الالتزامات والعقود الموريتاني ونفس الشيء بالنسبة للأمر القانوني رقم 127/83 المتعلق بالملكية العقارية والذي نص في المادة 27 على أنه يرجع إلى الشريعة الإسلامية في كل ما لا يتضمنه هذا القانون.

2 - العرف: يطلب العرف على العادات الملزمة التي تنظم سلوك الناس في المجتمع ويقوم على عنصرين:

أحدهما مادي والآخر معنوي فالأول يقتضي أن تكون هناك عادة عامة يجري التعامل بها في جميع البلاد أو في جهة أو في إقليم معين.

أما الثاني فيتمثل في اعتقاد الناس أن هذه العادة يجب اتباعها حيث إنها تعتبر في نظرهم من ضروريات السلوك في المجتمع وأنه يترتب الجزاء على مخالفتها. فالعنصر المعنوي إذاً في العرف شبيه بعنصر الإلزام في القاعدة القانونية.

والواقع أن إلزامية العرف عادة ما يكون مصدرها القانون سواء كان ذلك عن طريق الإقرار الصريح للعرف أو عن طريق إجازته في المعاملات، فقد وردت إشارات كثيرة إلى العرف في مختلف التشريعات وخاصة في مجال المعاملات المدنية والتجارية فقد أحال مثلاً ق. ا. ع. م. صراحة إلى العرف في حالات عديدة نذكر منها على سبيل المثال م 248 التي جاء فيها «كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية وهو لا يلزم بما وقع التصريح به فحسب بل أيضاً بكل ملحقات الالتزام الذي يقررها القانون أو العرف أو الإنصاف وفقاً لما تقتضيه طبيعته».

ومن نافلة القول إن العرف لا يمكن أن يخالف التشريع الوضعي ولا الشرع الإسلامي إذا كان مصدراً للقانون (الشريعة).

وقد نص ق. ا. ع. م. على ذلك صراحة في المادة 486 التي جاء فيها «لا يسوغ للعرف أو العادة أن يخالفا نصوص القانون».

ورغم ذلك فقد يكون العرف أقوى من التشريع في حالتين:

- العرف الدستوري بمثابة القانون الدستوري.
 - قد يعلو العرف أيضا على التشريع بإقرار من القانون ذاته.
 لذا نظرنا مثلا إلى المادة 525 من ق. ا. ع. م. نجدها تنص على ما يلي: «الالتزام
 الشيء يشمل أيضا تواجعه وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف فإن
 اتفاق ولا عرف اتبعت القواعد الواردة في المواد الآتية»..
 والمواد المشار إليها هي المواد من 526 إلى 539.

3 - القضاء: من المبادئ المعروفة في مختلف الأنظمة الجرمانية أن القاضي يطبق
 القانون ولا يشرع فهو يفصل في القضايا المطروحة على أساس القواعد القانونية التي يلتزم
 من دون تقديرها أما في القانون الإنجليزي فمن المعروف أن القاضي يرجع بالدرجة
 الأولى إلى الأحكام القضائية السابقة فيستند إليها بالفصل في القضية المطروحة عليه.
 ريتانيا سواء رجعنا إلى ما هو معمول به في الفقه الإسلامي أو إلى ما أخذته عن القانون
 رنسي فإنها تعمل بالمبدأ الذي مؤده أن القاضي يطبق القانون وربما يجتهد في تفسيره
 لكنه لا ينشئ القاعدة القانونية.

المطلب الرابع: المصادر التفسيرية

وسنتطرق فقط إلى أهم هذه المصادر على النحو التالي:

أولا: القضاء

وتتمثل مهمة القضاء في فض النزاعات بين الناس بتطبيق القانون المعمول به وهو
 بذلك يلزم الأفراد والمؤسسات بمراعاة القانون عن طريق توقيع الجزاء على من يخالفه
 وهو بذلك يضمن تحقيق ما يرمي إليه القانون من بسط العدالة وحماية النظام الاجتماعي
 واحترام حقوق الجميع.

وتحقيق هذه المهمة المناطة بالقضاء تتطلب منه تمتعه بالحرية الكافية المجردة
 من الخضوع للأفراد والضغط من أية جهة كانت ولذلك فإن القاضي ليس بموظف
 يخضع لأوامر رئيسه في الإدارة ولكنه يمارس وظيفته باستقلال في مواجهة الجميع وهذا
 ما نصت عليه الدساتير المتعاقبة في موريتانيا كدستور 59 - 61 - 91.
 وقد نصت جميع هذه الدساتير على أن التنظيم العام للدولة يقوم على الفصل بين
 السلطات الثلاثة (التشريعية، التنفيذية، القضائية).

ثانيا: الفقه

ويقصد به أعمال الفقه المختلفة من شرح وتفسير ونقد للتشريع كما
 أيضا النظريات والأنظمة القانونية المقارنة.
 فمهمته التعريف بالفكر القانوني ونشره وتطويره فكل تلك المهام منوطة
 وقد تطور دور الفقيه بالعصر الحاضر حيث أصبح المفسر للقانون وذلك